

1501889-08.2021.8.26.0024

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Leandro Augusto Gonçalves Santos

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... viciado em drogas é uma vítima do tráfico de drogas, e como tal não merece punição por sua conduta, mas sim tratamento. A lei 11.343/06 trata de forma mais branda o porte para uso de drogas, conforme dispõe o artigo 28, in verbis: Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua São Paulo nº 957, Centro, Andradina - 16901-009 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501889-08.2021.8.26.0024

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3055284/2021 - DISE-DEL.SEC.ANDRADINA, 18863216 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JOÃO VITOR DOS SANTOS VILELA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Artigo 28 da Lei 11.343/06

Aos 29 de março de 2022, às 14h28min, na sala de audiências da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Andradina, Comarca de Andradina, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Leandro Augusto Gonçalves Santos, comigo Escrevente ao final nomeada, funcionando como representante do Ministério Público a Dra. MARÍLIA GONÇALVES GOMES CANGANI (Promotora de Justiça), por meio do aplicativo Microsoft Teams, foi aberta a audiência virtual de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, e apregoadas as partes, fizeram-se presentes o defensor, Dr. Antonio Sergio da Fonseca Filho, bem como as testemunhas de acusação Marcell das Neves Rafael e Jota Teodoro Coimbra. Ausente o denunciado, citado e intimado a fls. 123. Iniciados os trabalhos, verificou-se nos autos, a fls. 129-132, a juntada de defesa prévia. Em seguida, pelo MMº. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como não se mostra presente quaisquer das circunstâncias previstas no artigo 395 do mesmo diploma processual. Ademais, a denúncia vem embasada em termo circunstanciado, instrumento que possui base probatória

suficiente para o oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 77, §1º da Lei 9.099/95. Por outro lado, a pequena quantidade de entorpecente, apreendida, não torna o fato atípico, sendo, de certo modo, conatural à classificação dada ao delito de que se trata. Pequena quantidade que não afasta o risco à saúde pública, de modo que se mantém a tipicidade da conduta imputada. Justamente por não ser elevada a quantidade de entorpecente, apreendida, restou, o suposto autor do fato, denunciado por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06, excluindo-se, assim, a possibilidade de configurar, o ilícito praticado, fato típico previsto no artigo 33 da Lei antes citada. Remanesce, no entanto, repito, a potencialidade lesiva à saúde pública, bem jurídico tutelado, justificando a permanência da incriminação, e afastando a possibilidade de aplicação do princípio antes referido. De outra sorte, não há qualquer impedimento a que o Estado vede o porte de substâncias consideradas especialmente prejudiciais à saúde, mesmo porque tais substâncias, disseminando-se, podem atingir, inclusive, crianças, amentais, e outras pessoas que não possuem perfeita capacidade de escolha. Inexiste proibição constitucional de se proceder, por meio de órgãos a este fim destinados, à diferenciação entre substâncias cujo uso, consumo, e porte, se revele lícito, apartando-se, destas, outras, que revelem maior probabilidade de dano à saúde, de tornar as pessoas delas dependentes e, assim, já não mais senhoras de sua própria vontade, em dano que não se revela apenas individual, mas atinge a sociedade, como um todo, inclusive no que tange ao pagamento dos custos necessários a financiar programas de tratamento e recuperação. Seria, aliás, rematado absurdo tratasse, o constituinte, de - analisando matéria que lhe é absolutamente estranha - vedar a possibilidade de diferenciação, antes apontada. Diante do exposto, recebo a denúncia. Tendo em vista que o réu não compareceu à audiência, embora citado e intimado (fls. 123), decreto-lhe a revelia." A seguir, pelo MMº. Juiz foram inquiridas as testemunhas de acusação Jota Teodoro Coimbra e Marcell das Neves Rafael, cujos depoimentos foram gravados em áudio e vídeo importados aos autos. Após, pelo defensor do réu foi dito que não havia testemunhas de defesa a serem ouvidas. Na sequência, encerrada a instrução, iniciaram-se os debates. Pela Dra. Promotora de Justiça foram apresentadas as alegações finais, de forma oral, as quais foram gravadas em áudio e vídeo importados aos autos. A seguir pelo Dr. Defensor do réu foi dito: Do Direito:

a) Da Inconstitucionalidade no caso concreto: O Direito Penal, segundo as modernas teorias do Direito, deve ser a ultima ratio, e deve ser chamado apenas para tutelar ofensa a bens jurídicos relevantes. É evidente que a vida do usuário de drogas que está se mutilando é um bem jurídico relevante, porém este bem é dele, e só a ele pertence. Utilizando drogas, o maior prejudicado é o usuário, e puni-lo é desarrazoado, pois seria apenas mais uma punição. Neste sentido cumpre salientar de que o viciado em drogas é uma vítima do tráfico de drogas, e como tal não merece punição por sua conduta, mas sim tratamento. A lei 11.343/06 trata de forma mais branda o porte para uso de drogas, conforme dispõe o artigo 28, in verbis: Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Luiz Flávio Gomes, em seu ministério classifica este tipo como uma infração penal sui generis, pois foge ao conceito de crime, que exige uma pena para sua configuração. Um tema relevante ao Direito, sobre o artigo em questão, é sua inconstitucionalidade, por afronta aos princípios constitucionais. Neste sentido, é relevante o ministério de Cristiano Avila Maronna: Para além da demonização de certas substâncias, não é mais possível à ciência jurídica ignorar a existência de um antagonismo evidente entre a destinação pessoal do consumo e a proteção jurídica à saúde pública: se o consumo é pessoal, afeta a saúde individual. Não há alteridade, apenas autolesão, o que inviabiliza a atuação do Direito Penal. Nullum crimen nulla poena sine iniuria. (...) Por todo o exposto, não há mais como prevalecer o vetusto - e equivocado - entendimento de que o consumo pessoal de drogas afeta a saúde pública. Tratando-se de conduta autolesiva, não há espaço para a intervenção penal. Por isso, o art. 28 da Lei 11.343/2006 é inconstitucional. Disponível

in: http://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/4739-Drogas-e-consumo-pessoal:-a-ilegitimidade-da-intervencao-penal Diante do exposto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 28 neste caso em concreto, uma vez que a conduta do réu consiste em autolesão, não tutelada pelo direito penal, e, por consequência, absolver o acusado. b) Do Princípio da Insignificância: Não bastasse a inconstitucionalidade do artigo no caso em concreto, ainda estamos diante de situação insignificante ao direito penal, uma vez que o réu foi encontrado com pequena quantidade de maconha, _____ gramas, que portava tão somente para seu consumo, de forma que esta quantidade de droga e a conduta do agente que trazia esta substância, não era capaz, de forma alguma, de ameaçar a saúde pública, que é o bem jurídico tutelado no tipo em questão. Neste sentido dispõe o Supremo Tribunal Federal no precedente do Habeas Corpus 110475, decisão que transcreve-se abaixo: PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ÍNFINA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. WRIT CONCEDIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 3. Ordem concedida. Desta forma, caso não seja reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 28 no caso concreto, requer o reconhecimento do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do caso em tela, com a consequente absolvição do acusado. c) Da Justiça Restaurativa: Caso o entendimento ainda seja diverso, e no sentido de uma condenação requer a aplicação dos princípios da justiça restaurativa, que tem como função recuperar o autor da infração. No caso dos autos, o autor declara-se usuário de drogas, e declarou em audiência o seu desejo de parar, de se livrar do vício, então, caso o entendimento, apesar de toda a argumentação no sentido contrário, seja pela condenação, requer a aplicação de medida social que vise a recuperação do réu, como assistir palestra sobre os efeitos da droga, ou a oportunidade de consultar-se com médico para ministrar tratamento. 3. Do Requerimento: Assim, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do Artigo 28 da lei 11.343/06, com a consequente absolvição do acusado por atipicidade do fato, uma vez que não há pena, nem crime quando não houver ofensa ao bem jurídico tutelado. Ora, se o bem jurídico tutelado é a saúde pública, e o réu com sua conduta pratica apenas uma autolesão, não tutelada pelo direito, não há que se falar em crime. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O pleito condenatório, no presente caso, é de ser atendido. Vejamos. A materialidade restou bem demonstrada, como deflui do auto de apreensão de fls. 13-14 e do laudo de fls. 20-21, restando, o exame químico-toxicológico, realizado, positivo. A autoria, por igual, revela-se indubitosa. Ouvido, em sede extrajudicial (fls. 10), o réu confessou, na íntegra, a prática delitativa. E tal confissão não desponta isolada, mas se apresenta em conformidade com o testemunho colhido, certo que a testemunha Marcell afirmou, às expensas, que o entorpecente foi encontrado no interior de veículo titularizado pelo réu, que prontamente o reconheceu, como seu, afirmando destinar-se a seu uso. A fim de que não restem dúvidas evitáveis, esclareço que o que a testemunha afirmou, possivelmente, ser cocaína, não foi reconhecido, como tal, em exame químico-toxicológico, realizado, nem foi, por isso, objeto de imputação, na denúncia, que se restringe, mesmo, à

maconha, encontrada. A situação fática, pois, quanto àquilo que restou imputado, é absolutamente clara, e não enseja qualquer dúvida. Inviável, por isso, cogitar-se de absolvição, por falta de provas. Por outro lado, ao contrário do alegado, pela defesa, a pequena quantidade de entorpecente, apreendida, não torna o fato atípico, sendo, de certo modo, conatural à classificação dada ao delito de que se trata. Pequena quantidade que não afasta o risco à saúde pública, de modo que se mantém a tipicidade da conduta imputada. Justamente por não ser elevada a quantidade de entorpecente apreendida, restou, o acusado, denunciado por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06, excluindo-se, assim, a possibilidade de configurar, o ilícito praticado, fato típico previsto no artigo 33 da Lei antes citada. Remanesce, no entanto, repito, a potencialidade lesiva à saúde pública, bem jurídico tutelado, justificando a permanência da incriminação, e afastando a possibilidade de aplicação do princípio antes referido. De outra sorte, não há qualquer impedimento a que o Estado vede o porte de substâncias consideradas especialmente prejudiciais à saúde, mesmo porque tais substâncias, disseminando-se, podem atingir, inclusive, crianças, amentais, e outras pessoas que não possuem perfeita capacidade de escolha. Inexiste proibição constitucional de se proceder, por meio de órgãos a este fim destinados, à diferenciação entre substâncias cujo uso, consumo, e porte, se revele lícito, apartando-se, destas, outras, que revelem maior probabilidade de dano à saúde, de tornar as pessoas delas dependentes e, assim, já não mais senhoras de sua própria vontade, em dano que não se revela apenas individual, mas atinge a sociedade, como um todo, inclusive no que tange ao pagamento dos custos necessários a financiar programas de tratamento e recuperação. Seria, aliás, rematado absurdo tratasse, o constituinte, de - analisando matéria que lhe é absolutamente estranha - vedar a possibilidade de diferenciação, antes apontada. Assim fixada a prática delitiva, passo à dosimetria da pena. A escolha da pena aplicável deve obedecer aos critérios e parâmetros inscritos no artigo 59 do Código Penal. O réu ostenta condenação transitada em julgado, como se vê da certidão de fls. 63-64 (feito sob nº 29-88), constatando-se, a partir de tal certidão, que o mesmo é reincidente, do que se vê que mera medida de advertência não seria suficiente aos fins de reprovação e prevenção do crime. Vai fixada, por isso, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 6 meses, duração que se revela necessária a obter os fins antes postos em relevo, bem como se apresenta justificada, tendo em vista a já apontada reincidência. Com efeito, o § 4º ao artigo 28 da Lei 11.343/06 não estabelece limite temporal mínimo à hipótese de que trata. Natural, tendo em vista a opção do legislador, concluir-se que este deva ser mais severo que os cinco meses endereçados, como limite máximo, ao não reincidente, pelo § 3º do mesmo artigo. De outra sorte, não se justifica a imposição de período mais alongado, mormente face à confissão espontânea, levada a efeito. Justificado, pois, o quantum imposto. A entidade beneficiária da prestação de serviços será definida, com prudente critério, pelo Juízo das Execuções. Defiro, ao réu, como não poderia deixar de ser, o direito de apelar em liberdade. Ante o exposto, julgo o pedido procedente, para, nos termos da fundamentação, condenar, o réu, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 6 meses, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06. A entidade beneficiária da prestação de serviços será definida, com prudente critério, pelo Juízo das Execuções. Defiro, ao réu, o direito de apelar em liberdade. Com o trânsito em julgado, oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se, à Justiça Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15, III, da Constituição da República. Comunique-se ao IIRGD e ao Distribuidor Criminal. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Registre-se. Este termo foi disponibilizado às partes, por elas conferido, e achado conforme, sendo assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz, nos termos do art. 25 da Resolução 185/2013 do CNJ: Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo. Eu, Ana Paula Amorim Leite Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA